

张某军、刘某伟对非国家工作人员行贿案

——国有建设用地使用权挂牌出让过程中串通竞买行为的定性

关键词 刑事 对非国家工作人员行贿罪 国有建设用地使用权 挂牌出让 串通竞买 串通投标

基本案情

2009年11月，安徽省濉溪县国土资源局挂牌出让某宗国有建设用地使用权。杨某（已判刑）借用某火公司资质报名竞买，某华公司、某盛公司、某利公司、某沙公司亦参与竞买。杨某为顺利摘牌，与被告人张某军商议采取给付补偿金的方式让其他公司放弃竞买。张某军与某盛公司副总经理马某中商量后，马某中同意接受人民币200万元（币种下同）退出；与某沙公司法定代表人邵某海、某利公司经理皇某利商量后，二人均同意接受250万元退出。被告人刘某伟根据张某军的安排，与某华公司法定代表人顾某峰商量后，顾某峰同意接受300万元退出。杨某通过张建军给马某中、皇某利分别转账200万元、250万元，通过刘某伟给顾某峰转账270万元（刘某伟以要分得30万元好处费为由，少给顾某峰转账30万元）。杨某与邵某海重新协商后将补偿金下调至120万元，并给邵某海转账120万元。

在该宗国有建设用地使用权挂牌出让竞买现场，上述四家公司未举牌或只举一次牌，杨某以8600万元的价格取得涉案国有建设用地使用权。综上，被告人张某军伙同杨某、刘某伟，以补偿金名义共计给予相关人员840万元。此外，张某军、刘某伟非法获利共计355万元，刘某伟在案发后退缴130万元。

检察机关指控被告人张某军、刘某伟犯对非国家工作人员行贿罪、

串通投标罪提起公诉。安徽省濉溪县人民法院于2013年6月14日作出（2013）濉刑初字第00117号刑事判决：一、被告人张某军犯对非国家工作人员行贿罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币六百万元。二、被告人刘某伟犯对非国家工作人员行贿罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币五十万元。三、被告人张某军、刘某伟违法所得人民币三百五十五万元，予以追缴。宣判后，张某军提出上诉。安徽省淮北市中级人民法院于2013年9月25日作出（2013）淮刑终字第00152号刑事裁定：驳回上诉，维持原判。

裁判理由

本案中，被告人张某军、刘某伟伙同他人在国有土地使用权挂牌出让过程中，贿赂参与竞买的其他公司的负责人放弃竞买，共计行贿840万元，数额巨大，其行为均已构成对非国家工作人员行贿罪，对此并无争议。本案争议焦点为，被告人张某军等人在国有建设用地使用权挂牌出让过程中与他人串通竞买，是否构成串通投标罪。《中华人民共和国刑法》第二百二十三条第一款规定：“投标人相互串通投标报价，损害招标人或者其他投标人利益，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。”鉴此，公诉机关关于张某军等人犯串通投标罪的指控不成立。具体理由如下：

其一，挂牌竞买不能等同于招投标。根据《招标拍卖挂牌出让国有建设用地使用权规定》（国土资源部令第39号）等相关规定，国有建设用地使用权可采用招标、拍卖或挂牌方式出让。其中，招标出让是指市、县人民政府国土资源行政主管部门（以下简称出让人）发布招标公告，邀请特定或者不特定的自然人、法人和其他组织参加国有建设用地使用权投标，根据投标结果确定国有建设用地使用权人；挂牌出让是出让人发布挂牌公告，按公告规定的期限将拟出让土地的交易条件在指定的

土地交易场所挂牌公布，接受竞买人的报价申请并更新挂牌价格，根据挂牌期限截止时的出价结果或者现场竞价结果确定国有建设用地使用权人。采用招标方式，投标人只有一次竞买机会，出让人可以否决所有投标，而采用挂牌方式，竞买人可以更新报价，出让人不得否决最高挂牌人。由此可见，挂牌竞买是一种独立于招投标的交易方式，二者不能等同。

其二，不宜将串通竞买类推适用于串通投标罪。国有建设用地使用权挂牌出让过程中的串通竞买行为具有一定的社会危害性，但刑法明确将串通投标罪限定在招投标领域，挂牌竞买和招投标无论在概念文义还是操作程序等方面都存在显著差异，不应将串通竞买解释为串通投标并进行定罪处罚，否则系类推解释，违反罪刑法定原则。相关行为符合对非国家工作人员行贿罪等其他罪名构成要件的，依法可以按照相应罪名依法惩处。

裁判要旨

串通投标罪系发生在招投标领域的犯罪。挂牌出让和招标出让是国有建设用地使用权出让两种相互独立的方式，行为人在国有建设用地使用权挂牌出让过程中串通竞买的，不符合串通投标罪的客观要件，依法不能认定串通投标罪。相关行为符合对非国家工作人员行贿罪等其他罪名构成要件的，应当按照相应罪名依法惩处。

关联索引

《中华人民共和国刑法》第164条

一审：安徽省濉溪县人民法院（2013）濉刑初字第00117号刑事判决（2013年6月14日）

二审：安徽省淮北市中级人民法院（2013）淮刑终字第00152号刑事裁定（2013年9月25日）